

1500096-24.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... "trazer consigo". De fato, o tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ - Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade. A confirmar o que se expõe:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500096-24.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500096-24.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048830/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23134548 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2048830 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE LUIS LOPES DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

ALEXANDRE LUÍS LOPES DE SOUSA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 20hs48min, na Avenida João Canal, 250, Jardim Iguatemi, nesta comarca de Bariri/SP, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 26 (vinte e seis) eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto de 24,04 g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Preso em flagrante durante o plantão judiciário, a prisão pré-cautelara foi convertida em prisão preventiva (fls. 104/107).

Defesa prévia às fls. 171/173.

Às fls. 199/200, foi recebida a denúncia.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais orais, sustentando estar provada a materialidade e autoria, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, pleiteando, ainda, o afastamento do privilégio do art. 33, §4º, da LD e tecendo considerações sobre a dosimetria da pena.

A Defesa, por sua vez, nas alegações finais de fls. 231/235, argumentou ser o réu mero usuário, já tendo sido internado compulsoriamente para tratamento da dependência química. Requereu a absolvição, apregoando insuficiência do conjunto probatório; subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da LD; ainda subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito se encontra formalmente em ordem, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, ainda, nulidade a sanar, passo ao exame do mérito.

A existência do fato (materialidade) está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fl. 04, boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 15 e pelo laudo pericial de fls. 226/229 e, ainda, pela prova oral coligida em Juízo.

Passo ao exame da autoria.

O réu, em seu interrogatório, declarou que eram seus apenas os cinco pinos de cocaína que foram encontrados consigo, para uso próprio. É dependente químico. Estava em regime aberto. Não ficava de madrugada nas ruas. Já foi internado compulsoriamente para tratamento da dependência química. Havia passado pelo local cerca de 08h25min, foi a uma biqueira. Já havia usado drogas, estava “eufórico”. Quando estava descendo com os cinco pinos, os policiais – que estavam em duas viaturas – foram atrás dele. O local é usado para guarda de drogas por outros usuários. Não dispensou sacola nenhuma. Havia outros policiais na abordagem. Falou que havia consigo cinco pinos de cocaína e dinheiro do seu serviço. O policial Marco Antônio se afastou um quarteirão e voltou com uma sacola. A sacola era verde. Nada tinha a ver com os entorpecentes que estavam na sacola. Os cinco pinos seriam usados em duas ou três horas.

Em que pese o relato do réu – que, como visto, admitiu somente a propriedade de parte das drogas, aduzindo que se destinava a consumo próprio –, a prova coligida demonstra, com segurança, a autoria do delito de tráfico.

Nesse caminho, a testemunha Marco Antônio de Oliveira, policial militar, declarou que estava em patrulhamento, juntamente com Sd. Bertholo. No bairro Iguatemi, visualizaram Alexandre abaixado em um terreno baldio, próximo a uma plantação de vassouras, mexendo em uma sacola plástica. Quando o réu viu a viatura, pegou o que havia, colocou no bolso, jogou a sacola, pegou uma bicicleta e saiu sentido contrário à viatura. Na abordagem, foram encontrados os eppendorfs com substância aparentando ser cocaína. Retornaram ao local onde ele havia abandonado a sacola, e lá, foram encontrados eppendorfs com as mesmas características. A sacola foi encontrada onde o réu estava antes. As embalagens eram idênticas. Visualizaram o réu nitidamente abaixado, no meio da plantação de vassouras, mexendo na sacola. A distância entre a viatura e o réu era de no máximo dez metros. Ao que se recorda, a sacola era azul.

A testemunha Edgar Callegari Bertholo, policial militar, declarou que na ocasião estava em patrulhamento com o policial Marco Antônio. Viram um indivíduo agachado, em um terreno, próximo ao meio-fio. Quando ele visualizou a viatura, se assustou, jogou uma sacola no terreno – que era uma plantação de vassouras – e saiu correndo

no contrafluxo da viatura. Em abordagem, localizaram cinco eppendorfs de substância aparentando cocaína, e uma quantia de dinheiro em espécie. Retornando ao local onde o réu estava, foi localizada uma sacola com outras porções de cocaína, em eppendorfs. A abordagem foi por volta das 20h. Alexandre já foi abordado outras vezes e já é conhecido dos meios policiais. Em outras abordagens, ele, testemunha, não encontrou entorpecentes, mas outros policiais já encontraram. Não lembra a cor da sacola.

Como se vê, as testemunhas prestaram depoimentos coesos, seguros e uníssonos, relatando que o réu trazia consigo - parte em seu bolso, parte na sacola que tentou dispensar - os 26 (vinte e seis) eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto de 24,04 g, descritos no auto de exibição de apreensão de fl. 15.

Não prevalece a versão de autodefesa de que os entorpecentes contidos na sacola não pertenciam ao réu, porquanto ambas as testemunhas policiais foram firmes no sentido de que o réu foi visto agachado, junto à plantação de vassouras, mexendo na sacola apreendida, que buscou ocultar dos agentes de segurança ao se deparar com a viatura.

E mais, tanto os eppendorfs que estavam no bolso do réu, quanto aqueles que estavam na sacola, tinham as mesmas características, conforme fotografia de fl. 36, com apenas alguns poucos pinos de cor distinta (alaranjados). Logo se vê, portanto, que faziam parte do mesmo conjunto pertencente ao réu.

Cumpram ressaltar, ainda, ter havido apreensão de R\$ 320,50 (trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) com o réu, em notas diversas (fl. 15), sem que Alexandre tenha apresentado indícios mínimos da origem lícita do dinheiro.

Além disso, a cocaína estava acondicionada em 26 eppendorfs (auto de exibição de fl. 15), ao modo usual de fracionamento para entrega de terceiros, circunstância indicativa de que se destinava a traficância.

Como percebo, não obstante a negativa do réu, o conjunto probatório demonstra, com robustez, a prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, na modalidade "trazer consigo". De fato, o tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ - Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade. A confirmar o que se expõe:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS SEPARADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que "para a

ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (Resp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 4.

Hipótese em que a condenação da paciente pelo delito de tráfico de drogas - posse de 233.63g de cocaína e 1,35g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal - está amparada em prova suficiente (auto de apreensão, laudo de constatação, depoimentos testemunhais e conversas obtidas mediante interceptação telefônica). Logo, a pretensão de absolvição por atipicidade da conduta demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido." (STJ. HC 496.536/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, não tendo sido apresentada nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, o TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador."

(RT 616/286-7).

Além disso, a condição de usuário não ilide necessariamente a de traficante e, não raras vezes, confunde-se no mesmo indivíduo, que faz do comércio ilícito a forma de sustentar o próprio vício.

Nessa quadra, o fato de o réu ter sido internado compulsoriamente para tratamento da dependência – conforme comprovam as certidões de objeto e pé juntadas aos autos – não afasta a autoria delitiva.

De fato, é firme o entendimento de que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, bastando, para a incursão no crime de tráfico, que o agente incorra em qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, como ocorreu no caso.

A corroborar o exposto: “A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.” (TJSP. Acórdão 1306853, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).

Portanto, não cogito a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

De outro lado, quanto ao privilégio previsto no art. 33, §4º, do Código Penal, o dispositivo prevê: “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”.

Impende asseverar que, na linha do entendimento do STF, a quantidade de droga, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 138715/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23.05.2017, Informativo 866).

No mesmo sentido tem o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, conforme HC 726.726/MG (relator Min. João Otávio de Noronha). No REsp n. 1.887.511/SP, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pelo Min. João Otávio de Noronha, especificamente com relação à natureza e quantidade das drogas apreendidas, definiu as seguintes balizas:

- a) Devem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena, pela necessidade de observância dos vetores indicados no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 como preponderantes;
- b) Não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena; e
- c) Supletivamente, podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

No caso dos autos, e observados rigorosamente os critérios legais e jurisprudenciais, tem-se que não cabe a aplicação da causa de diminuição.

Note-se que o réu não é primário e tampouco possui bons antecedentes, ostentando extenso histórico criminal, como se vê na certidão de fls. 73/80. Possui, inclusive, condenação transitada em julgado em data recente, pelo delito do art. 157 § 2º, II, do CP (processo de nº 1500113-24.2019.8.26.0062), tudo a demonstrar sua dedicação às atividades criminosas como meio de vida. Registro que o réu também ostenta mau antecedente por delito de tráfico, oriundo do processo de nº 0000195-40.2009.8.26.0302.

Assim, inaplicável a benesse prevista no art. 33, §4º, da LD.

Portanto, suficientemente comprovadas a existência e a autoria e participação pelo réu, e não se verificando a ocorrência de causa ou circunstância que exclua o crime

ou o isente de pena, é impositiva a responsabilização penal.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Em atenção às circunstâncias do caso em tela, não é o caso aplicar a sanção-base acima do mínimo legal pelo fato de a droga apreendida ser “cocaína”.

Consoante entendimento do TJSP, “(...) a natureza da substância (cocaína), por si, não impõe, necessária e automaticamente, o aumento da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena” (TJSP; Apelação Criminal 1501716-98.2019.8.26.0526; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2021; Data de Registro: 26/01/2021).

Assim, e tendo em vista que os requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade) são cumulativos (STJ, HC Nº 567.261 – RJ, - DJe: 16/06/2020), a quantidade e a natureza da droga apreendida, no caso destes autos, não justificam o aumento da pena.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

Conforme certidão de fls. 73/80, o réu possui mau antecedente, ante a condenação nos processos de nº 0000210-55.2006.8.26.0062, 0004797-86.2007.8.26.0062 e 0000195-40.2009.8.26.0302 (não se aplicando, aos maus antecedentes, o período depurador, conforme pacífica jurisprudência do STJ). As condenações nos processos de nº 0002349-62.2015.8.26.0062 e

1500113-24.2019.8.26.0062 serão consideradas na fase subsequente.

Os motivos do crime são normais à espécie.

As consequências foram normais.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta, deve ser considerada normal.

Não há falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago).

Logo, de rigor o aumento da pena-base, de modo que, considerando uma circunstância judicial negativa (mau antecedente); fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase do cálculo, não incidem atenuantes. Rememoro, no item, a Súmula 630 do STJ (“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”).

Noutro giro, o réu é multirreincidente (art. 61, I, do CP), ante as condenações nos processos de nº 0002349-62.2015.8.26.0062 (0001277-12.2019.8.26.0026) e 1500113-24.2019.8.26.0062 (0000559-78.2020.8.26.0026), não atingidas pelo período depurador (fls. 73/80).

Em razão da multirreincidentência, reputo suficiente o agravamento da pena na fração de 1/4, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, na etapa intermediária, agravo a pena e a fixo em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 728 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena final em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 728 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Regime inicial

Diante do quantum da pena imposta e da reincidência, fixo ao réu o regime inicial FECHADO.

Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal

Não há falar em aplicação da regra prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (detracção penal). O benefício não se confunde com progressão de regime; e, ainda, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução (STJ, HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe15/06/2018).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Ante o quantum da pena e reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Ainda, é também incabível a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP.

Indenização mínima

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conforme art. 387 do CPP, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ALEXANDRE LUÍS LOPES DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 728 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

“Status Libertatis”: pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderá o réu recorrer em liberdade. Mostra-se, pois, imperiosa a manutenção do sentenciado no cárcere, não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública.

Logo, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o necessário.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Expeça-se a guia de execução provisória. Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Transitada em julgado:

a) intime-se o réu para pagamento da multa;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Decreto o perdimento do valor apreendido e objetos apreendidos em favor da União.

Com o trânsito em julgado, oficie-se (Lei 11.343/06, artigo 63, § 1º).

Expeça-se certidão de honorários ao Defensor Dativo, conforme Termos/Valores do Convênio OAB/Defensoria.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA